

대법원 2025. 9. 4. 선고 2025도9690, 2025보도72 판결

【강요·강제추행·유사강간·강요미수·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(촬영물등이용협박)·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(촬영물등이용강요)·아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물제작등)·아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물제작·배포등)·미성년자의제강제추행·미성년자의제유사강간·아동복지법위반(아동에대한음행강요·매개·성희롱등)·사기·아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물소지등)·미성년자의제강제추행미수·보호관찰명령】 , [공2025하,1851]

【판시사항】

- [1] 법조경합의 한 형태인 특별관계의 의미 및 법조경합으로서 실질적으로 1죄인지 또는 수죄인지 판단하는 기준
- [2] 피해자를 도구로 이용한 간접정범 형태로 유사강간죄나 강제추행죄가 성립하는 경우, 별도로 강요죄가 성립하는지 여부(소극)

【판결요지】

- [1] 법조경합의 한 형태인 특별관계란 어느 구성요건이 다른 구성요건의 모든 요소를 포함하는 외에 다른 요소를 구비하여야 성립하는 경우로서, 특별관계에 있어서 특별법의 구성요건을 충족하는 행위는 일반법의 구성요건을 충족하지만 반대로 일반법의 구성요건을 충족하는 행위는 특별법의 구성요건을 충족하지 못한다. 법조경합은 1개의 행위가 외관상 수 개의 죄의 구성요건에 해당하는 것처럼 보이나 실질적으로 1죄만을 구성하는 경우를 말하며, 실질적으로 1죄인가 또는 수죄인가는 구성요건적 평가와 보호법익의 측면에서 고찰하여 판단해야 한다.
- [2] 형법 제324조 제1항의 강요죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 한 때’에 성립하고, 형법 제297조의2의 유사강간죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기를 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위’를, 형법 제298조의 강제추행죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행’한 경우에 성립한다. 강요죄는 개인의 의사결정 또는 의사실행의 자유를 보호법익으로 하는 반면, 유사강간죄와 강제추행죄는 사람의 성적 자기결정권 또는 성적 자유를 보호법익으로 하고 있어, 강요죄는 개인적 자유를 침해하는 범죄에 대하여 일반법의 관계에 있으므로, 피해자를 도구로 이용한 간접정범 형태로 유사강간죄나 강제추행죄가 성립하는 경우 별도로 강요죄가 성립하지 않는다.

【참조조문】

- [1] 형법 제37조 / [2] 형법 제37조, 제297조의2, 제298조, 제324조 제1항

【참조판례】

[1] 대법원 2003. 4. 8. 선고 2002도6033 판결 (공2003상, 1127), 대법원 2004. 1. 15. 선고 2001도1429 판결 (공2004상, 368), 대법원 2025. 5. 15. 선고 2024도16239 판결 (공2025하, 1111)

【전문】

【피고인 겸 피보호관찰명령청구자】 피고인 겸 피보호관찰명령청구자

【상 고 인】 피고인 겸 피보호관찰명령청구자

【변 호 인】 변호사 강윤영

【대상판결】

【원심판결】 부산고법 2025. 6. 11. 선고 2025노69, 2025전노1, 2025보노4 판결

【주문】

상고를 모두 기각한다.

【이유】

1. 피고사건에 관하여

가. 죄수관계에 관한 법리오해 주장에 대하여

1) 법조경합의 한 형태인 특별관계란 어느 구성요건이 다른 구성요건의 모든 요소를 포함하는 외에 다른 요소를 구비하여야 성립하는 경우로서, 특별관계에 있어서 특별법의 구성요건을 충족하는 행위는 일반법의 구성요건을 충족하지만 반대로 일반법의 구성요건을 충족하는 행위는 특별법의 구성요건을 충족하지 못한다 (대법원 2003. 4. 8. 선고 2002도6033 판결 등 참조). 법조경합은 1개의 행위가 외관상 수 개의 죄의 구성요건에 해당하는 것처럼 보이나 실질적으로 1죄만을 구성하는 경우를 말하며, 실질적으로 1죄인가 또는 수죄인가는 구성요건적 평가와 보호법익의 측면에서 고찰하여 판단하여야 한다 (대법원 2004. 1. 15. 선고 2001도1429 판결, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2024도16239 판결 등 참조).

2) 이 사건 공소사실 중 피해자 공소의 1 에 대한 ‘나체 동영상 촬영’ 관련 강요, ‘가슴·음부 사진, 자위 동영상 촬영’ 관련 강요, 피해자 공소의 2 에 대한 ‘음부 사진 촬영’ 관련 강요, ‘자위 동영상 촬영’ 관련 강요 부분은 피고인 겸 피보호관찰명령청구자(이하 ‘피고인’이라고 한다)가 위 피해자들을 협박하여 위 피해자들로 하여금 사진 또는 동영상 촬영의 의무 없는 일을 하게 하였다는 것이고, 피해자 공소의 1 에 대한 강제추행 및 유사강간, 피해자 공소의 2 에 대한 강제추행 및 유사강간 부분은 피고인이 위 피해자들로 하여금 위 가슴·음부 사진 또는 나체·자위 동영상을 촬영하도록 하여 강제추행 또는 유사강간을 하였다는 것이다.

3) 형법 제324조 제1항의 강요죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 한 때’에 성립하고, 형법 제297조의2의 유사강간죄는 ‘폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체

(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기를 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위'를, 형법 제298조의 강제추행죄는 '폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 수행'한 경우에 성립한다. 강요죄는 개인의 의사결정 또는 의사실행의 자유를 보호법익으로 하는 반면, 유사강간죄와 강제추행죄는 사람의 성적 자기결정권 또는 성적 자유를 보호법익으로 하고 있어, 강요죄는 개인적 자유를 침해하는 범죄에 대하여 일반법의 관계에 있으므로, 피해자를 도구로 이용한 간접정범 형태로 유사강간죄나 강제추행죄가 성립하는 경우 별도로 강요죄가 성립하지 않는다.

4) 그럼에도 원심이 판시와 같은 이유로, 강요죄와 별도로 강제추행죄 또는 유사강간죄가 성립하고 양자가 상상적 경합관계에 있다고 보아 이 부분 공소사실을 모두 유죄로 판단한 것은 법조경합 관계에 있는 위 각 죄의 죄수에 관한 법리를 오해한 것이다. 그러나 결과적으로 처단형의 범위에는 아무런 차이가 없는 점, 위 각 죄가 법조경합 관계에 있어 유사강간죄나 강제추행죄만 성립한다고 보아 유사강간죄나 강제추행죄에 대하여 정한 형으로 처벌할 경우에도, 원심과 같이 위 각 죄가 별도로 성립하되 상상적 경합관계에 있다고 보아 무거운 죄인 유사강간죄나 강제추행죄에 대하여 정한 형으로 처벌하는 경우와 비교하여 실질적으로 양형의 조건이나 그에 따른 선고형에 차이가 없을 것으로 보이는 점 등의 사정에 비추어, 죄수의 평가에 관한 원심의 판단이 판결에 영향을 미쳤다고 볼 수는 없다(대법원 1980. 12. 9. 선고 80도384 전원합의체 판결, 대법원 2022. 10. 27. 선고 2022도10402 판결 등 참조). 따라서 이 부분 상고이유 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 나머지 상고이유에 대하여

원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 강요미수죄의 성립 등에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락한 잘못이 없다.

2. 보호관찰명령 청구사건에 관하여

피고인이 피고사건에 관하여 상고를 제기한 이상 보호관찰명령 청구사건에 관하여도 상고한 것으로 의제된다. 그러나 상고장에 이유의 기재가 없고, 상고이유서에서도 이 부분에 관한 불복이유를 찾아볼 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 엄상필(재판장) 오경미(주심) 권영준 박영재